



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תיק מס': 22/13

בפני כב' המפקחת י. ענתבי-שרון

התובעת: **רחל יוסף**
ע"י ב"כ עו"ד נדב ישעיהו

- נ ג ד -

הנתבע: **יוסף פרש**
ע"י ב"כ עו"ד ענת בן דרור

פ ס ק – ד י נ

עניינו של פסק דין זה בהסגת גבול ובבניית מחסן על שטח הרכוש המשותף.

א. העובדות

1. עסקינן בבית משותף הידוע כגוש 30415 חלקה 175, והנמצא ברחוב בוליביה 7 בירושלים (להלן: **"הבית המשותף"**).
2. בבית המשותף 24 דירות, 3 קומות ו- 4 כניסות. בכל כניסה 6 דירות המחולקות ל-2 עמודות כאשר בכל עמודה 3 דירות, זו על גבי זו.
3. התובעת היא בעלת זכויות החכירה בדירה הידועה כחלקת משנה 12 בבית המשותף, ששטחה 40.2 מ"ר, ולה 1/24 חלקים בלתי מסוימים ברכוש המשותף. הנתבע הוא בעל זכויות החכירה בדירה הידועה כחלקת משנה 10, ששטחה 40.1 מ"ר וגם לו- 1/24 חלקים בלתי מסוימים ברכוש המשותף.
4. דירות הנתבע והתובעת מצויות באותה עמודה (להלן: **"עמודת הצדדים"**). בעלי הדירה השלישית בעמודה זו הם שרון וענבל בן-שטרית, שאינם צד להליך (להלן: **"בן שטרית"**).
5. התובעת רכשה את דירתה מהגב' שמירה דוידוב ביום 16.9.10 (להלן: **"דוידוב"**). קודמתה של דוידוב בדירה הייתה הגב' ורה שפירא (להלן: **"שפירא"**) [יוער כי בנסח הרישום ההיסטורי מצוין כי בין שפירא לבין דוידוב היו רשומים כבעלים בני משפחת רבינוביץ'].
6. בהתאם לרישום במרשם המקרקעין, לדירת התובעת, כמו גם לדירת הנתבע, לא מוצמדים חלקים מסוימים מן הרכוש המשותף. גם בתקנון המוסכם של הבית המשותף מיום 21.3.80, אין כל הוראות בנוגע להצמדות מיוחדות או לשימוש ייחודי ברכוש המשותף.
7. בקומת המרתף של עמודת הצדדים בנויים שלושה מחסנים (להלן: **"קומת המרתף"**), אשר אינם מוצמדים, כאמור, לאף אחת מהדירות. השימוש הייחודי בשלושת המחסנים מתחלק בין הנתבע לבין



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בן שטרית. התובעת אינה עושה שימוש כלשהו בקומת המרתף בהיעדר מקום פנוי, וזאת על אף שגם היא מעוניינת לבנות בו מחסן לשימושה.

8. בתביעה זו עותרת התובעת לסילוק ידו של הנתבע מאחד המחסנים בעמודת הצדדים. למען הבהרת המונחים, נכנה להלן את השטח המצוי בעמודה בה מצויות דירות הצדדים, וממנו מבקשת התובעת לפנות את הנתבע, כ"שטח המחלוקת". שטח זה הוא השטח המצוי בקומת המרתף של הבית המשותף ואשר סומן בתשריט אשר צורף לכתב התביעה, וכן לתשריט אשר צורף לכתב ההגנה (מדובר בתשריט זהה) כ- "מחסן מוצע לפי החלטת ועדת ערר".

9. בשנת 2005 הגישו הנתבע ובן שטרית בקשה להיתר (0950.06/1980). לפי תכנית ההיתר (מוצג 1) מסומנים 3 מחסנים שווים בגודלם, החולשים על כל קומת המרתף בעמודת הצדדים. אחד המחסנים סומן בתכנית זו במילים "מחסן בן שטרית", השני סומן במילים "מחסן משפ' פרזי" והשלישי- "מחסן בעתיד".

10. על פי הנטען בכתב התביעה, במהלך ספטמבר 2010, עת רכשה התובעת את דירתה מדוידוב, היו ההליכים בהם פתחה דוידוב לקבלת היתר בניה עבור בניית מחסן על הרכוש משותף, בעמודה הסמוכה לעמודת הצדדים, בעיצומם. ההיתר שהגישה דוידוב (בקשה מספר 0950.07/1980) הוא לבניית תוספת ליחידת דיור אחת בקומה העליונה, תוספת הכוללת ממ"ד חדר ומרפסת גג, ובנוסף התבקש גם היתר לבניית מחסן בעמודה הסמוכה לעמודת הצדדים.

11. הבקשה לבניית מחסן בעמודה סמוכה נבעה מכך שכל קומת המרתף בעמודת הצדדים הייתה "תפוסה", וזאת משום שהנתבע ובן שטרית בנו בה, כאמור, מחסנים לשימושם ולא נותר עוד מקום לבניית מחסן לשימוש דירת התובעת.

12. הועדה המקומית אישרה את הבקשה להיתר, בתנאים, ועל החלטה זו הגישו חלק מדיירי העמודה הסמוכה ערר לוועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה- מחוז ירושלים (להלן: "ועדת הערר"). בעררם התנגדו לכך שיתאפשר לבעל דירה שדירתו איננה מצויה באותה "עמודה", לבנות בה מחסן. דיירי העמודה הסמוכה טענו כי קיים שטח לבניית שלושה מחסנים בכל עמודה, בהתאמה למספר הדירות המצויות שם ועל כן התנגדו כי מי שאינו בעל דירה בעמודה שלהם יבנה בה מחסן לשימוש (ראה נספחים ד' ו-ה' להודעה בדבר צירוף מסמכים מטעם התובעת מיום 28.4.13).

13. בהחלטתה מיום 2.11.10 קיבלה ועדת הערר את הערר, וקבעה, בין היתר, כי: "לא יינתן היתר למחסן מבקשי ההיתר (דוידוב- י.ע.ש) מתחת לעמודת העוררים. עם זאת, החלטה זו ניתנת על רקע כך שאכן העוררים יממשו את הזכות שלהם למחסנים, יש לתת למבקשי ההיתר אפשרות לנצל את השטח למחסן עבורם".



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

14. התובעת תיקנה את בקשת ההיתר ובסופו של דבר, ביום 13.6.12, ניתן לתובעת היתר בניה לבניית מחסן בשטח המחלוקת (וזאת על אף ששטח זה תפוס בפועל על ידי הנתבע).

15. לטענת התובעת, פניות חוזרות ונשנות אל הנתבע לפנות את שטח המחסן, עליו השתלט לטענתה, עלו בתוהו ולפיכך הוגשה תביעה זו בה מבקשת התובעת - **"להוציא צו לפינוי המחסן באופן מיידי ולחייב את הפולש בהחזר דמי השכירות שקיבל ומקבל מאז ועד עצם היום הזה"**.

ב. עיקרי טענות הצדדים

16. בפתח הדברים יוער כי במועד בו הוגשו כתב התביעה וכתב ההגנה, וכן בשלב בו נערך קדם המשפט הראשון, לא היו הצדדים מיוצגים.

עיקרי טענות התובעת

17. התובעת טוענת כי כפי שעולה מתכניות הנתבע למתן ההיתר, לרבות התשריט ומסמכי הבקשה (מוצג 1, נספח א' להודעת התובעת בדבר צירוף מסמכים מיום 28.4.13), בן שטרית והנתבע פנו לרשויות התכנון בבקשה לבנות **שני מחסנים** בעוד השלישי (ה"מחסן לעתיד") יוותר מחסן "פתוח".

18. לטענת התובעת, הנתבע מעולם לא קיבל היתר בניה מרשויות התכנון כדין לבנות מחסן על שטח המחלוקת. יתרה מכך, הנתבע אף לא קיבל, לטענתה, את הסכמת כל בעלי הדירות בבניין להצמיד בפועל את המחסן בשטח המחלוקת לדירתו ולעשות בו שימוש ייחודי.

19. התובעת טוענת עוד כי הנתבע שינה את גרסתו מקצה לקצה לאחר שבחר להסתייע בעורך דין לשם ייצוגו. כך, לטענת התובעת, בעוד שבתחילת ההליכים עמד על כך שקיבל היתר בניה לבניית שלושה מחסנים וכי כל מה שבנה נעשה בהיתר, שינה מאוחר יותר את גרסתו וטען בה כי קיבל את הסכמת גב' שפירא המנוחה לשם עשיית שימוש ייחודי במחסן המצוי בשטח המחלוקת. לשיטת התובעת יש בשינוי גרסה זה ובטענותיו הכבושות של הנתבע בכדי לפגום באמינות טענותיו.

20. התובעת מדגישה כי טענת הנתבע לקבלת הסכמתה של הגב' שפירא לעשיית שימוש ייחודי בחלק המחסן המיועד לה, הוא שטח המחלוקת, לא הוכחה ולא נתמכה בכל ראיה.

21. עוד טוענת התובעת כי אף אם הייתה ניתנת לנתבע הסכמת הגב' שפירא (דבר המוכחש על ידה כאמור), הרי שאין בכך כדי לסייע לנתבע שכן, לכל היותר, הייתה זו הסכמה למתן זכות שימוש. מאחר וכך, טוענת התובעת, בעלות הדירה שבאו בנעלי שפירא (דוידוב ולאחר מכן התובעת) רשאיות היו לחזור בהן מהסכמה זו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

22. התובעת מבקשת לתת משקל משמעותי להודאת הנתבע לפיה על אף שהמחסן בשטח המחלוקת יועד לדירת התובעת, הרי שלאחר שבן שטרית השתלט על המחסן שיועד לנתבע לא נותרה לו עוד ברירה אלא לעשות שימוש בשטח המחסן המיועד לתובעת, הוא שטח המחלוקת.

23. התובעת טוענת כי נטל ההוכחה להראות כי הנתבע קיבל את הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף לעשיית שימוש ייחודי בשטח המחלוקת מוטל על כתפיו, וזה לא צלח להרימו. התובעת מדגישה בהקשר זה כי גם מהדיונים אשר התקיימו בפני ועדת הערר עולה כי הנתבע הטעה את בעלי הדירות וכי הם עצמם הלינו על כך שהנתבע השתלט על שטח המחלוקת ועשה בו כבשלו.

24. התובעת מוסיפה כי מכל מקום, אף אם קיבל הנתבע היתר בניה כדין מרשויות התכנון בנוגע לשטח המחלוקת, הרי שאין בכך די, שכן מן הבחינה הקניינית לא קיבל הנתבע את הסכמת בעלי הדירות כדין.

25. עוד טוענת התובעת כי הנתבע לא דאג לכנס את האסיפה הכללית של בעלי הדירות ועל כן ממילא לא התקבלה החלטה המתירה לו לעשות שימוש בשטח המחלוקת. התובעת טוענת בהקשר זה כי הסכמת בעלי הדירות יכולה לחייב דיירים חדשים רק אם ההסכמה ניתנה בצורת החלטה הרשומה בספר הפרוטוקולים של האסיפה הכללית. משעה שלא התקבלה החלטה כזו וממילא היא לא מצויה בספר הפרוטוקולים, היא איננה מחייבת את התובעת אשר באה בנעליהן של שפירא ודווידוב.

26. לפיכך, התובעת טוענת כי יש להורות על סילוק ידו של הנתבע משטח המחלוקת וכן לפסוק לזכותה דמי שימוש ראויים. לטענתה, זכותה לקבלת דמי שימוש (דמי שכירות כמבוקש בכתב התביעה) נעוצה בכך שהנתבע לא עשה שימוש סביר בשטח המחלוקת ומנע מהתובעת לממש את זכויותיה בשטח זה.

עיקרי טענות הנתבע

27. בכתב ההגנה, אשר הוגש כאמור ללא ייצוג, נטען כי הנתבע מחזיק בהיתר בניה כדין שניתן לו בשנת 2006, בהתאם לבקשה שהגיש יחד עם בן שטרית. נטען שם, כי ההיתר שניתן בשנת 2006 מתייחס לשלושה מחסנים (דהיינו חולש גם על שטח המחלוקת) וכי הוא עצמו מחזיק במחסן בהתאם לחלוקה בינו לבין "השכן האחר" (אשר בדיעבד התברר כי הוא בן שטרית). בדיון המקדמי שהתקיים בפני ביום 20.3.13, חזר וטען הנתבע בתוקף כי הוא זה שקיבל היתר בנייה, כבר בשנת 2006, עבור בניית המחסן בשטח המחלוקת. גם בדיון המקדמי שלאחר מכן (אשר התקיים ביום 2.5.13) עמד על טענתו כי בנה מחסן בשטח המחלוקת ברישיון וכי עורך הבקשה של התובעת הגיש למעשה בקשה על שטח לא רלוונטי (שכן, כאמור, לשיטת הנתבע באותו שלב כבר ניתן לו היתר לבנות בשטח המחלוקת והוא בנה מחסן בהתאם להיתר זה ובו הוא עושה שימוש).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

28. היות וגם לאחר שני דיונים מקדמיים ואף לאחר שהוריתי לכל צד להמציא את המסמכים התומכים בטענה ההדדית כי הבניה ב"שטח המחלוקת" בוצעה בהתאם להיתר בניה שקיבל כל אחד מהם כדין (לטענת התובעת בסביבות שנת 2011 ולטענת הנתבע כבר בשנת 2006), לא התבררו פני הדברים (שכן, בין היתר, כל אחד מהם צרף את אותו התשריט וטען כי המחסן המצוי בשטח המחלוקת הוא מחסן שנבנה בהיתר כדין שניתן לו), הוריתי לוועדה המקומית להבהיר למי ניתן היתר הבניה לגבי אותו מחסן בשטח המחלוקת. יוער כי לשם קבלת עמדת הוועדה המקומית הועבר התשריט אשר צורף לכתב ההגנה של הנתבע, ולפי הנטען בכתב ההגנה, מדובר על מחסן שניתן לו עבורו היתר בניה כדין.

29. תשובת יו"ר הוועדה המקומית, מר קובי כחלון, התקבלה ביום 20.6.13 ובה הובהר כי : **"תוספת הבנייה והמחסן המוצע בהיתר מ' 104499 מיום 25.6.12 שייכת לדירת דוידוב שמירה ת.ז. 314529025..."**

30. לאחר קבלת עמדת הוועדה המקומית, ובשלב בו כבר היה הנתבע מיוצג, התקבלה ביום 16.5.13 **"הודעה מטעם הנתבע"** ובה הוצגה גרסה חדשה להשתלשלות האירועים : בהודעה זו הבהיר הנתבע כי: **"בטעות צורפה לכתב הגנתו התכנית המתוקנת של דוידוב עם המילים 'מחסן מוצע לפי החלטת ועדת ערר', אותה צילם מתוך תיק הבקשה של דוידוב בעירייה, בעדו שלמעשה התכוון לצרף את תכנית ההיתר שלו- נספח א' לעיל" (ראה בעמ' 3 להודעה סעיף כ')."**

31. נספח א' להודעה הוא נוסח פרסום הבקשה בתיק 0950.06/1980 שם מצוין, בין היתר, כי מבוקשת: **"... הקלה בדבר בניית 2 מחסנים בקומת מסד במסגרת 8% משטח הדירה"**. נראה כי כוונת הנתבע היא דווקא לנספח 2 להודעתו, שהוא תשריט בו מסומנים שלושה מחסנים- מחסן בן שטרית, מחסן משפ' פרזי וכן "מחסן בעתיד". מיקום ה"מחסן בעתיד" זהה למיקום המחסן המצוי בתשריט שצורף לכתב התביעה ושם הוא מסומן כ"מחסן מוצע לפי החלטת ועדת ערר". מדובר, למעשה, בשטח המחלוקת.

32. בהתאם לאמור באותה הודעה, הבקשה שהגישו הנתבע ובן שטרית לקבלת היתר בניה הוגשה בשנת 2005 והתבקש בה רישיון לתוספת בניה ל-2 מתוך 3 הדירות שבעמודה וכן תוספת לקומת מרתף לצורך בניית מחסנים לדירות. באשר למחסנים, סומן בהיתר מחסן לדירת הנתבע, מחסן לדירת בן שטרית וכן "מחסן לעתיד". ה"מחסן לעתיד", בהתאם לנטען בהודעה זו, יועד לגבי שפירא, שהיא קודמתה של דוידוב בדירה.

33. ביום 20.2.06 ניתן היתר בניה מס' 55680 בבקשה 0950.06/1980 (נספח ב' להודעה) ל"תוספת קומת מרתף + תוספת ל-2 דירות בחזית מזרחית".



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

34. בסיכומיו הבהיר הנתבע כי תוספת הבנייה, אשר התבקשה בבקשת ההיתר שהגיש יחד עם בן שטרית, יושבת על כל קומת המרתף והיא המהווה יסוד לבנייה. על כן לטענת הנתבע, מטבע הדברים, נתבקש היתר גם לבניית קירות התוחמים את המחסן השלישי (שטח המחלוקת) כדי שעליו תיבנה התוספת.

35. הנתבע הוסיף וטען בהודעה זו, כי בן שטרית לקח את שטח המחסן המיועד לנתבע, סגר ותחס אותו והכשיר אותו לשימוש. הנתבע, שלטענתו ניהל מערכת יחסים טובה מאוד עם שפירא, פנה אליה וביקש את הסכמתה לכך שהוא ייקח את המחסן שיועד לשימושה (המחסן בשטח המחלוקת). שפירא, לטענתו, אשר הייתה "גלמודה וערירית" הודיעה מראש כי אינה זקוקה למחסן, ולבקשתו אף נתנה לו מרצונה החופשי ובהסכמתה המלאה **"את כל זכויותיה במחסן"**.

36. הנתבע טען שהוא הכשיר את המחסן בשטח המחלוקת לשימושו בהוצאה כספית משמעותית וזאת בהסתמך על כך שהגב' שפירא ויתרה על כל זכויותיה במחסן והעבירה אותו אליו.

37. עוד טען הנתבע, כי הדבר נעשה בהסכמת כל השכנים בעמודה זו של הבניין, וכי אף יתר בעלי הדירות בחלקים האחרים של הבית המשותף לא הביעו התנגדות, ולא היה להם כל עניין להתערב במה שקורה בכניסה זו. בסיכומיו הוסיף הנתבע כי ניתן ללמוד על הסכמת יתר בעלי הדירות מכך שאלו חתמו על בקשת ההיתר שהגיש לרשויות התכנון.

38. בסיכומיו הוסיף וטען הנתבע כי התובעת קיבלה היתר בניה לבנית המחסן בעמודת הצדדים מאחר והטעתה את רשויות התכנון, שכן, לטענתו, סימנה על גבי המסמכים שהציגה כי היא מבקשת לקבל היתר לבניית מחסן במקום שהוצע כביכול על ידי ועדת הערר. לטענת הנתבע, ועדת הערר כלל לא הציעה את המיקום הפרטני אליו הפנתה הנתבעת ולפיכך היתר הבניה ניתן לה כביכול נוכח הטעיה.

39. הנתבע הדגיש בסיכומיו כי מחקירתה הנגדית של התובעת עלה כי היא איננה יודעת או איננה זוכרת פרטים רבים ומהותיים וכי למעשה כל ידיעותיה בנוגע לתקופה שקדמה לרכישתה את דירת דווידוב נשענות על שמועות ותו לא.

40. נטען כי על אף שמדובר ברכוש משותף, הרי שיש הגיון קנייני ותכנוני לייחד את קומת המחסנים בכל עמודה לדיירי אותה העמודה וכי בפועל, הזכויות במחסן שנועדו לשמש את שפירא הועברו לנתבע בהסכמת דיירי הכניסה ושאר דיירי הבית המשותף, אשר לא הביעו התנגדות.

41. נטען עוד כי בשנת 2007, לאחר פטירתה של הגב' שפירא, נמכרה הדירה לדווידוב. הדירה שנמכרה לדווידוב, כך על פי הטענה, לא יכולה הייתה להימכר עם מחסן או עם זכות למחסן, שכן המחסן (המצוי בשטח המחלוקת) כבר לא היה חלק מהדירה ו"אין אדם יכול למכור יותר ממה שיש לו".

42. הנתבע טוען כי משניתן שטח המחלוקת לנתבע במתנה מהגב' שפירא והנתבע השקיע בו ממון, והכשיר אותו לשימוש, נוצרה לנתבע זכות קניינית בלתי הדירה להחזיק בשטח זה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

43. כך נטען עוד, כי משעה שהמתנה לא נרשמה בפנקסי המקרקעין היא מהווה לכל היותר התחייבות לעשות עסקה. הנתבע טוען, בהסתמך על סעיף 5 לחוק המתנה תשכ"ח-1968, כי נותן המתנה יכול לחזור בו מהתחייבותו כל עוד "מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות". הנתבע טוען כי הוא שינה גם שינה מצבו לרעה בהסתמך על התחייבות זו ולכן אין כל אפשרות לחליפתה של הגב' שפירא (היא התובעת) לחזור בה ממתן המתנה.

44. הנתבע ער לעובדה כי לא נרשמו הצמדות כלשהן של מחסנים לדירות פרטניות, אולם טוען כי הסיבה היא כי לא נעשה תיקון רישום הבית המשותף ואילו היה נעשה תיקון כזה, לפני שהתובעת רכשה את דירתה, מן הסתם היו משקפים בתשריט את המצב המצוי ויוצרים לכל אחת מן הדירות "הצמדה" של המחסן השייך לה.

45. נטען עוד כי משניתנה הסכמת כל הדיירים לבקשת ההיתר שהגישו בן שטרית והנתבע, יצא שטח המחסנים מן הרכוש המשותף והפך להצמדה ספציפית. לטענת הנתבע, העובדה כי ההצמדה לא עוגנה ברישום איננה שוללת את הזכויות בה. לתמיכה בעמדתו מפנה הנתבע אל דברי ועדת הערר לפיהם "הרישום איננו חזות הכל, לא מבחינה קניינית ולא מבחינה תכנונית" ומכך מבקש ללמוד כי לו היו מתקנים את רישום הבית המשותף היו מצמידים את המחסנים לדירות שבנו אותם.

46. הנתבע טוען כי כפועל יוצא מהעובדה שעם קבלת הסכמת השכנים והיתר הבניה, המחסנים יצאו מהרכוש המשותף, אין להתייחס כלל לדרישה לתשלום דמי שימוש.

ג. דיון והכרעה

המסגרת המשפטית

47. "רכוש משותף" מוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") כך:

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".

48. סעיף 55 לחוק, הדרן ב"חלקי הרכוש המשותף הצמודים לדירות" קובע כך-

(א) לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסויים ברכוש המשותף של אותו בית משותף.

(ב) עיסקה בדירה תחול גם על החלק ברכוש המשותף הצמוד אליה, ואין תוקף לעסקה ברכוש המשותף בנפרד מן הדירה; אין בהוראה זו כדי למנוע פעולה הבאה להקטין או להגדיל את שטח הקרקע שברכוש המשותף.

(ג) בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג', לפרק זה (להלן - התקנון), שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלוגית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד.

49. סעיף 62 (א) לחוק קובע :

"בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלוגית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (ההדגשה שלי- י.ע.ש).

50. הצמדה היא "עסקה במקרקעין" שאיננה מתבצעת באמצעות הגשת בקשה ושטר עסקה אלא על ידי קביעת הוראות בתקנון המוסכם. התקנון מקבל תוקף כלפי צדדים שלישיים רק אם נרשם (ראה בסעיף 62(ג) לחוק). כך, כל אדם המעיין בנסח הרישום יוכל לדעת האם חלק מסוים של הרכוש המשותף הוצא מתוכו והוצמד לדירה פלוגית בבית המשותף. סעיף 62(ג) לחוק והמילים "קיים תקנון מוסכם" בו רשומה ההצמדה, מופיעות בכל דף מדפי הרישום של הדירות, לרבות הדירות שלהן אין הצמדה (ראה: א' אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** (בתים משותפים) (בורסי, תשס"א-2011) בעמ' 116-117).

51. שימוש ייחודי של בעל דירה ברכוש משותף, כמוהו כ"הצמדה בפועל". כאשר בעל דירה תופס חזקה ייחודית ברכוש המשותף, הוא מונע בכך לצמיתות מבעלי דירות אחרים לעשות שימוש באותו חלק של הרכוש המשותף. לכך, נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות (ראה : ת"א (מחוזי- ת"א) 2816/03, **צפורה קונצ'יצקי נ' דליה שפלן**, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 3.4.06, ע"א 2525/92, **גבי וקרני ראוכברגר נ' עיריית רמת גן**, פ"ד מז (5) 850, רע"א 698/85, **בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח'**, תק-על 87 (2) 732, א. אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק ג', 114-115).

52. המחוקק מצא לנכון, במסגרת תיקון 18 לחוק המקרקעין (חוק המקרקעין (תיקון מס' 18) התשנ"ה-1995), להקל בדרישת ההסכמה **שעה שמדובר בהרחבה של דירה**, כחריג לכלל הקבוע בסעיף 62 לחוק המקרקעין. לאמור, כאשר חלק מן הרכוש המשותף מתווסף לדירה על מנת להגדיל את שטחה, יידרש רוב מופחת של 3/4 מבעלי הדירות ש-2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, בלבד (ראה סעיף 71 ב לחוק המקרקעין). יש להדגיש שרוב מופחת זה יפה רק כאשר מדובר בהרחבת דירה. "הרחבה" מוגדרת בסעיף 71 לחוק כ- **"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף"**.

53. מהי אם כן "ההסכמה" הנדרשת? נקבע, כי כאשר עסקין בויתור על זכויות **קנייניות נדרשת הסכמה מפורשת וברורה ואין די בהסכמה שבשתיקה או בהסכמה משתמעת** (ראה: ע"א 7388/97 **עזבון משה שמיר ז"ל נ. יעל דולב (שמיר)** פ"ד נה 690). עוד הוכרע כי אין צורך בהסכמה בכתב וגם



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הסכמה על פה הסכמה היא (ראה: ר"ע 815/81, **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו (3) 78, ע"א (מחוזי-ת"א) 1020/03, **בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף** (פורסם ב"נבו". ניתן ביום 25.4.04).

54. כאשר עסקינן במתן **זכות שימוש ייחודית במקרקעין** (להבדיל ממתן זכות קניינית), אזי ניתן ללמוד על הסכמה, גם על דרך של הסכמה שבשתיקה, הסכמה מכללא, על דרך בחינת התנהגות הצדדים במשך השנים (ראה: ע"א 32/77, **טובליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים**, פ"ד לא (3) 210, ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06, **רונית לומברוזו נ' קובנר מיכאל ואח'**, (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 7.8.07).

55. העובדה שעבר **זמן רב** מאז תפס אדם את הקרקע ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו וליצור רישיון מכללא. בע"א 32/77 לעיל נקבע בעניין זה כך:

"הלכה פסוקה היא... שלשם יצירת רישיון של שימוש במקרקעין אין צורך בהסכם מפורש ומספיקה, התנהגותם של בעלי הדין שממנה ניתן להסיק שהסכימו בדיעבד והשלימו עם שימושו של אדם אחר ברכושם. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס האדם את הקרקע, ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו, וליצור רישיון מכללא (implied license) שלא היה קיים מלכתחילה..."

56. יפים לעניין זה גם דבריה של פרופ' נינה זלצמן:

"לצד רשות שניתנה בהבטחה מפורשת ניתן לתאר מצבים שבהם נלמדת הסכמתו של בעל מקרקעין, ומכאן רשותו, משתיקתו ואי מחאתו על ההחזקה של פלוני בנכס, או על השימוש שהוא עושה בנכס, כאשר בנסיבותיו של המקרה ניתן היה לצפות את התנגדותו. במצבים אלה ההחזקה או השימוש הושגו במעשה עוולה של הסגת גבול במקרקעין. אך השלמתו של בעל מקרקעין עם נוכחותו של פלוני בנכס מניחה עם עבור הזמן את הסכמתו שבשתיקה... הסכמה זו משמעותה היתר של רצון טוב המתחדש מרגע לרגע כל עוד לא גילה בעל המקרקעין את דעתו שהוא חפץ בסיומו..."

(פרופ' נ. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב' חוברת א', בעמ' 128- להלן "זלצמן")

57. להבדיל מהסכמה למתן זכות קניינית, הסכמה למתן זכות שימוש במקרקעין היא זכות אישית, ממנה ניתן לחזור בכל עת (ראה: זלצמן, בעמ' 57, מ. דויטש, קניין, כרך ב' (התשנ"ט-1999), 414).

58. רק במקרים מיוחדים, בהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושהם קיימת הסתמכות של בעל הרישיון על ההסכמה, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על הציפייה הלגיטימית שלהם (ראה: ע"א 7139/99 **אלוני נ' ארד ואח'**, פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 **קוגלמס נ' קוגלמס**, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 **אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח'**, פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 **ציזיק נ' הורוביץ ואח'**, פ"ד



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן ואח', פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם באתר נבו)).

59. כך למשל, במקרה בו נתן בעל מקרקעין לבתו מתנה מבנה שהיה בנוי על חלקתו על מנת שתגור בו לאחר שתינשא, אולם המתנה לא התגבשה כדי רישום זכויות הבת, פסק בית המשפט העליון כי יורשי האב לא זכאים לבטל את הרישיון שנתן האב לבתו, לאור נסיבות המקרה המעידות כי בהסתמך על ההבטחה השקיעה הבת כספים רבים ועבודה רבה בשיפוץ המקום והפכה מבנה עזוב לבית מגורים אשר שימש אותה במשך 25 שנה (ראה: ע"א 588/81 לעיל).

60. נקבע עוד כי הסכמה על פה תחייב גם צדדים שלישיים, היינו חליפם של בעלי דירה שנתנו הסכמתם, **רק אם ידעו על קיומה** (כך נפסק לגבי מתן זכויות במקרקעין וניתן ללמוד מקל וחמור ביחס למתן זכות שימוש במקרקעין- ראה: ר"ע 815/81 לעיל ו- ע"א (מחוזי- ת"א) 1020/03 לעיל. יוער עוד כי פסיקה זו מתייחסת להסכמה מפורשת שנתנו בעלי דירה קודמים).

61. עוד נקבע, כי יש להקפיד הקפדה יתרה על שמירת זכויותיהם הקנייניות של בעלי דירות בבית משותף ולהישמר פן תתפרש שתיקתו של בעל דירה כהסכמה ממנה לא ניתן יהא לחזור. יפים לעניין זה דברים שנאמרו בת"א (מחוזי – ת"א) 2816/03, **ציפורה קונצ'יצקי נ' דליה שפלן**, לעיל-

"בהסקת מסקנות בדיעבד בדבר אישור השימוש הייחודי בגג הבית המשותף יש משום הגמשה של כללי ניהול הבית המשותף, שלילת הוודאות ומתן אפשרות ליצירת זכויות על ידי קביעת עובדות בשטח. אישור שכזה מנוגד לתכלית הראויה...ואולם, גם בהנחה המיטיבה עם המשיבים ששתיקת המערערים במשך השנים מהווה מתן הרשאה לשימוש הייחודי שאותו עשו בגג הבית, הרי לכל היותר אפשר לראות את השימוש כנעשה בגדר הדוקטרינה של "רישיון במקרקעין" ללא תמורה. כפי שנפסק לא אחת, הרשאת חינם שכזו ניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון... על פי ההלכה הפסוקה, רק במקרים נדירים שבהם הוענקה לבעלי הרישיון גם הרשות לבנות ובהסתמך על מתן רישיון לצמיתות השקיעו בעלי הרישיון במקרקעין, הכירו בתי המשפט בטענה בדבר אי הדירות של הרשות...".

62. לא למותר עוד להעיר כי על רקע הלכות אלה, מובן שאין ללמוד מקבלת היתר בנייה מן הרשות המקומית לשם בניה על הרכוש המשותף, כי קיימת ההסכמה הדרושה בהיבט הקנייני, של בעלי הדירות.

63. לא אחת נפסק, כי רשויות התכנון אינן דנות ומכריעות בסוגיות קנייניות וכי ההחלטה בדבר מתן היתר בנייה על ידן תקפה לדלת אמות ההליך התכנוני. לא פעם נקבע, כי אין להשוות בין ההסכמות והשיקולים הנוגעים לדיני התכנון והבניה לשיקולים והדרישות הנובעים מחוק המקרקעין (להבדל בין שיקולי הקניין לשיקולי ועדות התכנון ראה למשל בג"צ 1578/90, **הלן אייזן נ' הועדה המקומית**



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לתכנון ובניה תל אביב, ניתן ביום 24.10.90, פורסם ב"נבו". כך למשל, נקבע כי- "אין חולק, כי סמכות מוסדות התכנון מוגבלת לדיון בשאלות תכנוניות, וכי אין הם מוסמכים לדון בשאלות קנייניות: "בשום מקרה לא תכרענה הועדות בשאלות הקנייניות לגופו של הענין, הואיל והפונקציה המוטלת עליהן היא תכנונית בלבד" (עניין אייזן הנזכר; ראו גם פסק דינו של השופט ג'ובראן בע"מ 3493/08 שחמון נ' רשות הרישוי המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו (לא פורסם), פסקה 20). לגישה זו טעם מבורר, הועדות אינן מוסמכות בדיון וגם אין מומחיותן בשאלות קניין; עליהן לפעול על יסוד תשתית קניינית נתונה ומובהקת. מנגד, מוסדות התכנון רשאים לדון בבקשה גם במצב בו בעלי זכויות בנכס מתנגדים לבקשה מטעמים תכנוניים" (ראה: ע"מ 2832/09, הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ' בני אליעזר, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 9.1.11).

64. לנושא זה גם השלכה נוספת, במישור מקביל, היינו העובדה כי ניתן היתר בניה לבנית מחסן זה או אחר על ידי רשויות התכנון המוסמכות, אין פירושו כי המחסן הופך להיות בבעלותו של מקבל ההיתר מבחינה קניינית.

65. על רקע האמור לעיל, נפנה לבחון את נסיבות העניין הפרטני שלפנינו.

מן הכלל אל הפרט

סיווג שטח המחלוקת

66. מצינו לעיל, כי במקרה דנן אין כל שינוי בצו הבית המשותף ובתקנון המוסכם ולא נרשמו הצמדות מיוחדות לדירת הנתבע. הספקולציות אותן מעלה הנתבע בסיכומיו אינן חורגות מגדר "ניחוש" גרידא, שכן כפי שהוא עצמו מודה, לא נעשה כל ניסיון מצד בעלי הדירות לבצע תיקון של צו הבית המשותף והתקנון המוסכם. לפיכך, אין לדעת אם ניסיון זה, ככל שהיה רוקם עור וגידים, היה צולח לשביעות רצון הנתבע- אם לאו. מכל מקום, כל עוד לא תוקן צו הבית המשותף אין מדובר במתן זכות קניינית אלא לכל היותר- מתן זכות לשימוש ייחודי במקרקעין.

67. הנה כי כן, משלא הוצמדה קומת המרתף - כולה או חלק ממנה - לדירה מסוימת בבית המשותף, היא מהווה, על פי הגדרת סעיף 52 לחוק, רכוש משותף.

סוגיית ההסכמות לשימוש ייחודי ברכוש משותף

מהו רף ההסכמות הדרוש לשם עשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף?

68. כפי שהובהר לעיל, היות ועסקינן ברכוש משותף, הרי שלשם עשיית שימוש ייחודי בו יש צורך בהסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף.

69. יוער כי במצב דברים בו מבקש בעל דירה לבנות מחסן לדירתו, כאשר המחסן איננו מהווה חלק אינטגרלי מדירתו, שכן איננו צמוד אליה פיסית, כבמקרה דנן, לא ניתן לראות בכך "הרחבה"



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

כמשמעותה בסעיף 71 א לחוק (ראה: רע"א 1462/10 **דוד עטייה נ' ליאור שגיא**, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 2.8.12, א. אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק ג', 222). במקרה הנדון הבהיר הנתבע בעדותו כי הוא משכיר מחסן זה, ששטחו כ-10 מטרים, לצד שלישי, ולמעשה- אין המחסן מהווה חלק מדירתו אלא יחידה נפרדת – "ש. ... היום החלוקה בפנים היא שני מחסנים לבן שטרית ואחד לך? ת. כן. ש. יש יחידת דיור כיום? ת. כן, כ-10 מטר. ש. כמה אתה מרוויח ... ת. 1,500 ₪. ש. כמה זמן אתה משכיר את זה למגורים? ת. אולי שלוש שנים, זה היה סגור בהתחלה למחסן..." (ראה פרוטוקול הדיון מיום 3.7.13, עמ' 9 שורות 41,45, עמ' 10 שורות 1, 27).

70. ודוק: במקרה הנדון מדובר בבית משותף המחולק לכניסות ואגפים שונים והוא אף כולל עמודות נפרדות בכל כניסה וכניסה. דא עקא, כי בצו רישום הבית המשותף ובתקנון המוסכם לא הוצמד באופן פרטני הרכוש המשותף המצוי בתחומי כל כניסה לאותה הכניסה או לעמודותיה. לפיכך, הרי שהשטח שבמחלוקת מהווה רכוש משותף של כלל בעלי הדירות בבית המשותף, כך שלצורך עשיית שימוש ייחודי בו יש צורך לקבל את הסכמתם של כל 24 בעלי הדירות.

71. בשים לב למסקנה זו, הרי שיש לדחות את טענת הנתבע לפיה קיבל "מתנה" משפירא. שטח המחלוקת מהווה רכוש משותף ולא היה מעולם בבעלותה הבלעדית של שפירא. לפיכך ממילא לא יכלה שפירא להעניק במתנה זכויות קנייניות שאינן בבעלותה. לכל היותר הסכמתה, ככל שאכן ניתנה, יכולה הייתה להתייחס לשימוש ייחודי בחלקה הבלתי מסוים ברכוש המשותף. בשים לב למסקנה זו, אין גם צורך להידרש לשאלה האם חזרה בה שפירא ממתן המתנה כדין.

האם ניתנו לנתבע הסכמות בעלי הדירות?

72. כעולה מסיכומי, הנתבע מסתמך על הסכמת בעלי הדירות להיתר הבניה שניתן לו ולבן שטרית להרחבה ולבניית מחסנים. עיון במוצג 1 (תכנית ההיתר) מלמד כי מדובר בתכנית הנוגעת להרחבת דירות הנתבע ובן שטרית וכן לבניית מחסנים. בקומת המרתף מסומן, כאמור בפרק העובדות, מחסן לדירת בן שטרית וכן לדירת הנתבע וכן "מחסן לעתיד". גם אם כטענת הנתבע, לצורך בניית ההרחבות לדירתו ולדירת בן שטרית היה צורך לבנות את קירות המחסנים (לשם תמיכה), ולכן הבקשה להיתר עניינה בבניית שלושה מחסנים, אין הדבר מלמד כי בעלי הדירות אשר נתנו הסכמתם להיתר בניה זה הסכימו לשימוש הבלעדי שיעשה הנתבע במחסן המסומן "מחסן לעתיד" – הוא שטח המחלוקת. בצורה מפורשת סומן שטח המחלוקת כ"מחסן לעתיד" ולא כמחסן מוגמר של משפחה זו או אחרת (כפי שסומן ביחס למחסנים האחרים "מחסן משפ' פרזי" ו- "מחסן בן שטרית") שאמור להיבנות ככזה במסגרת ההיתר. אין אלא ללמוד מכך כי לכל היותר מדובר בבניית עמודים אשר ישמשו בעתיד למחסן ותו לא. על כן ממילא מהסכמות בעלי הדירות להיתר זה לא ניתן ללמוד על הסכמתם לכך שהנתבע הוא שיעשה שימוש בלעדי באותו "מחסן לעתיד", שטח המחלוקת.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

73. זאת ועוד. הנתבע אף לא הציג כל אסמכתא להסכמת בעלי הדירות לאותה בקשה שלו לקבלת היתר בנייה. כשנשאל על ההסכמות שקיבל מבעלי הדירות ענה "כולם הסכימו בכניסה שלי" (ראה שם, בעמ' 11, שורה 11. ההדגשה אינה במקור). כשנשאל אם יש בידי פרוטוקול המלמד על הסכמות שניתנו ענה: "לא, אין לי השכן החתים את כולם והעביר את זה לעירייה" (שם, עמ' 11 שורה 14).

74. על אף תשובה זו בחר הנתבע שלא להציג את ההסכמות הכתובות שניתנו לו לטענתו, וזאת על אף שבנקל יכול היה לצלמן מתיק העירייה. דברים ברורים נאמרו בפסיקה אודות הימנעות מהבאת ראיות, ובין השאר, על ידי כב' השופטת בן עתו (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פ"ד לה (1) 736 (1980), בעמ' 760, מול האותיות ה-ו):

"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראייה שהיא לטובתו ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים וככל שהראיה יותר משמעותית כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות יותר מכריעות ויותר קיצוניות נגד מי שנמנע מהצגתה".

בעניין זה ראה גם: ע"א 635/89 אנקונה נ' גוטמן תק-על 90(3) 705 (1990); ע"א 27/91 קבלו נ' שמעון פ"ד מט (1) 450 (1995); יעקב קדמי על הראיות - הדין בראי הפסיקה (מהדורה משולבת ומעודכנת, תשס"ד), עמ' 1650.

75. מעבר לכך, כשנשאל הנתבע בחקירתו האם ניתנה לו הסכמת שפירא במועד הגשת הבקשה להיתר ענה בהתייחס לגב' שפירא: "בזמן הבקשה היא (לא) נתנה את ההסכמה שלה". (שם, בעמ' 8 שורה 40). גם תשובתו זו סותרת לכאורה את תשובתו לפיה לבקשה להיתר הסכימו לכאורה כל בעלי הדירות בכניסה שלו.

76. בין המסמכים אותם הציגה התובעת כראיות מטעמה (ראה הודעה בדבר צירוף מסמכים מיום 28.4.13 וכן ההפניה למסמכים אלו בתצהיר עדותה הראשית) צורף כנספח ה' פרוטוקול הדיון בוועדת הערר מיום 2.11.10. מדובר בדיון שהתקיים בערר שהגישו בעלי הדירות בעמודה הסמוכה לעמודת הצדדים על החלטת הוועדה המקומית לאשר לתובעת לבנות מחסן בעמודה בה מצויות דירותיהם. בפרוטוקול זה (אשר לקבילותו לא התנגד הנתבע ובהתאם להחלטת מיום 2.5.13 יש לראותו כראייה קבילה) אומרים אותם בעלי דירות, בין היתר, את הדברים הבאים:

הגב' נחמה שושנה שוסטק (להלן: "שוסטק"), אשר מנסח הרישום עולה כי היא בעלת זכויות החכירה בתת חלקה 7 (אשר איננה מצויה בכניסת או בעמודת הצדדים) אמרה את הדברים הבאים:

" פרש (הנתבע- י.ע.ש) לקח שני מחסנים והוא עושה דברים מאוד מאוד לא חוקיים כי הוא לא גר אצלנו. לנו בעמודה שלנו זה מחולק לשלושתנו כי אנחנו מתחילים לבנות....



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

אסור לתת לו מתנה שיהיה לו שני מחסנים ולכן אנחנו לא אשמים על הבעיה שיש להם."

(ראה נספח ה' להודעת התובעת בדבר צירוף מסמכים, עמ' 2, שורות 12-13, 29-30).

77. כנשאל הנתבע בחקירתו הנגדית על הסכמתה הנטענת של הגברת שוסטק אמר כך :

"ש. תסכים איתי שהשכנים שאתה טוען שהם הסכימו, הסכימו על סמך תכנית מוצג 1.

ת. נכון.

ש. בין האנשים שחתמו הייתה הגב' נחמה שוסטק.

ת. כן וודאי.

ש. אני אומר לך שבדיון בערר, הגב' שוסטק אמרה, מצטט מעמ' 2 שורה 13, איך אתה אומר שהיא הסכימה.

ת. היא אישה חולה, היא לא שייכת לעמודה שלנו, והפריע לה ששמים פסולת שכנים אחרים מתחת לבית שלה ומאחר וזה מעבר פרוזדור אל המחסנים כיסיתי את זה כדי שיהיה מעבר יותר יפה".

78. התשובה שסיפק הנתבע מתייחסת ל"ברזנט ירוק" אותו הוא הציב בעמודה בה גרה שוסטק ואילו התייחסה שוסטק במקום אחר בדיון בפני ועדת הערר (שם, בעמ' 2 לפרוטוקול שורות 28-30). אולם, הנתבע לא סיפק תשובה בנוגע לדבריה המפורשים של שוסטק כנגד השימוש שהוא עושה במחסן בעמודת הצדדים. טענת הנתבע להסכמתה כביכול של שוסטק אף אינה עולה בקנה אחד עם תשובתו המוקדמת יותר לפיה ההסכמות שניתנו הם של בעלי הדירות בכניסה בה מצויות דירות הצדדים ("בכניסה שלי").

79. בשים לב לכך שלא ניתן ללמוד מהיתר הבניה על הסכמת בעלי הדירות לשימוש הייחודי שעושה הנתבע בשטח המחלוקת ובהתחשב בכך שלא הוצגו הסכמות בעלי הדירות, אין אלא לדחות את הטענה לקבלת הסכמת בעלי הדירות לשימוש הייחודי שעושה הנתבע בשטח המחלוקת.

האם די בהסכמת מפורשת של בעלי הדירות בכניסת או בעמודת הצדדים?

80. כאן יש לפנות לבחינת שאלה נוספת והיא האם אכן התקבלו הסכמות בעלי הדירות בכניסת הצדדים או בעמודת הצדדים. ככל שתענה השאלה בחיוב, הרי שאז קם הצורך לבחון אם יש ממש בטענת הנתבע לחלוקה מוסכמת בפועל של שטחי הרכוש המשותף של כל עמודה ועמודה לבעלי הדירות באותה עמודה, מכוח נוהג או חלוקה מוסכמת אחרת שבהתנהגות. אם אכן קיימת חלוקה שכזו בפועל, הרי שאז יתעורר הצורך להכריע האם במקרה דנן, על אף שלא הוצאו חלקים מהרכוש המשותף והוצמדו לדירות מסוימות, די בהסכמת בעלי הדירות בעמודה/ בכניסה בה מצויות דירות הצדדים, ככל שאלו אכן ניתנו.

81. הנתבע, כזכור, טען כי קיבל את הסכמתה של הגב' שפירא לעשות שימוש ייחודי בשטח המחלוקת, בעל-פה. עדות הנתבע לא הייתה מהימנה ואינני מקבלת את גרסתו. טענתו להסכמתה של הגב'



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

שפירא היא טענה כבושה שהתפתחה והשתכללה על ציר הזמן. כפי שפורט לעיל, טענה זו הועלתה רק בשלבים מתקדמים במהלך בירור ההליך ולאחר שהוגש מטעם הנתבע כתב הגנה והתקיימו שתי ישיבות מקדמיות. אף לאחר שהועלתה הטענה, היא לא גובתה בכל ראייה חיצונית מלבד לעדות הנתבע, שלא מצאתי אותה כמהימנה כלל וכלל.

82. לו אכן היה בטענה זו מן האמת, סביר היה כי הנתבע היה מעלה אותה בהזדמנות הראשונה ומצהיר בריש גלי כי השימוש הייחודי שהוא עושה במחסן נעשה בהסכמת שפירא ובברכתה. העובדה כי לא עשה כן ולא טען זאת אלא בעיצומם של הליכים אלו, יש בה כדי להפחית מאמינות טענתו זו באופן ניכר.

83. אמנם, הנתבע הציע להיבדק בבדיקת פוליגרף, אולם התובעת סירבה לכך. ידוע כי בבדיקת פוליגרף יכולה להוות ראייה בהליך אזרחי, כל עוד היא מושגת בהסכמת הצדדים (ראה: ע"א 61/84 **ביאזי נ' לוי**, מב(1) 446), רע"א 6383/98 **הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' סרחאן**, תקדין עליון (1999). משעה שלא ניתנה הסכמת התובעת, לא ניתן היה לבחון את עדות התובע בעזרת מכשיר זה. לא מצאתי כי יש לתת להצעתו זו כל משקל.

84. מאחר והגעתי למסקנה כי לא הוכח ששפירא נתנה הסכמתה, הרי שממילא אין צורך לבחון האם די בהסכמת בעלי הדירות בעמודת הצדדים, מכוח חלוקה או נוהג שלפיו קומת "המחסנים" בכל עמודה ועמודה מיועדת לשימושם של בעלי הדירות באותה עמודה.

85. עם זאת ולמעלה מן הצורך אעיר כי גם בהקשר זה לא מצאתי לקבל את טענת הנתבע. טענתו כי בפועל כל קומת מרתף, בכל עמודה, משמשת רק את בעלי הדירות באותה עמודה לא גובתה בראיות מספקות, ונטענה כלאחר יד. הנתבע לא הציג ראיות משכנעות המלמדות כי בעלי דירות אחרים בנו מחסנים רק בקומת המרתף שבעמודה שלהם וכי בפועל אכן התבצעה החלוקה הנטענת. אף אם יש בחלוקה זו הגיון, הרי שאין בכך די ולא ניתן לקבל את הטענה בהיעדר ראיות להוכחתה.

86. גם לא מצאתי כי יש בהחלטת ועדת הערר בכדי ללמד על החלוקה בפועל הנטענת. אמנם, מטענות שוסטק ואדלר בדיון בפני ועדת הערר, עולה כי לדידן נכון לבצע חלוקה שכזו ואף ועדת הערר ציננה כי לשיטתה קיים הגיון קנייני ותכנוני בחלוקה מסוג זה. יחד עם זאת, אין בכך די בכדי ללמד כי בפועל אכן קיימת החלוקה הנטענת. כאמור, הטענה לא גובתה בראיות מספקות, כך למשל הנתבע לא הזמין לעדות בעלי דירות בכדי ללמד כי בנו מחסן רק בעמודה בה מצויות דירותיהם או כי בפועל השימוש שנעשה בקומת המחסנים בכל עמודה הוא רק של בעלי הדירות באותה עמודה. הנתבע אף לא הציג כל ראיות משכנעות אחרות לתמיכה בגרסתו זו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הסכמה מכללא, הסתמכות ושינוי מצב לרעה

87. כאמור, לטענת הנתבע עצם ההימנעות של יתר בעלי הדירות מלפעול כנגד השימוש הייחודי שהוא עושה בשטחי הרכוש המשותף, יש בה כדי להעיד על הסכמתם מכללא לשימוש זה.

88. "הסכמה מכללא" נלמדת, כאמור ברקע המשפטי שפורט לעיל, מחלוף **זמן רב** מאז תפס אדם את הקרקע. אין די בהימנעות שאיננה מתפרשת על פני זמן ארוך טווח בכדי ללמוד ממנה על מתן הסכמה מכללא, שאם לא כן הרי שכל תפיסה קצרת טווח ובמקביל הימנעות בעל הזכויות מלנקוט כנגדה פעולה מעשית, תחשב כהסכמתו של בעל המקרקעין מכללא למתן רישיון שימוש במקרקעין (ראה: ע"א 32/77 לעיל, ע"א 588/81, בג"ץ 45/71 **קרושבסקי נ' עיריית תל-אביב-יפו**, פ"ד כה(1) 792, 797-796). גם על רקע ההלכות המורות כי יש לנקוט זהירות רבה פן תחשב שתיקת בעל דירה בבית משותף להסכמה על ויתור על זכויותיו הקנייניות (ראה למשל ת"א (מחוזי – ת"א) 2816/03 לעיל) יש לפרש את דרישת הפסיקה ל"חלוף זמן רב" באופן שבו רק חלוף זמן ארוך במיוחד ומשמעותי מרגע תפיסת השימוש במקרקעין יוכל להעמיד את בעל הזכויות במקרקעין בחזקת מי שהסכים לתפיסה זו.

89. במקרה הנדון קיבל הנתבע את היתר הבנייה להרחבה ובניית קומת מחסנים ב- 20.2.06, כפי שעולה מהיתר הבניה המצורף כנספח ב' לתצהיר עדותו הראשית של הנתבע. לא נטען בפני כי הבקשה להיתר נגעה להכשרת בניה בדיעבד, ולפיכך יש להניח כי רק לאחר קבלת ההיתר החל הנתבע לבנות את המחסן בשטח המחלוקת ולאחר מכן גם לעשות שימוש בקומת המחסנים, לרבות בשטח המחלוקת. התובעת הגישה את תביעתה ביום 10.1.13, וזאת, יש להניח, לאחר שניסיונותיה להוביל לפינוי של הנתבע מרצון לא נשאו פרי. הנה כי כן, לכל היותר עשה הנתבע שימוש בשטח המחלוקת כשש שנים טרם הגשת כתב התביעה. בעדותו אף ציין הנתבע כי רק כשלוש שנים הוא משכיר את שטח המחלוקת למגורים, שכן קודם לכן היה שטח זה סגור כמחסן (פרוטוקול מיום 3.7.13, עמ' 10 שורות 29-30).

90. בנסיבות אלו אינני סבורה כי קמה חזקת "ההסכמה מכללא", שכן לא חלף זמן רב ממועד תפיסת החזקה בשטח המחלוקת ועד להגשת התביעה דנן. לפיכך, הימנעות מלפעול כנגד הנתבע במהלך פרק זמן לא ארוך זה, אין משמעה הסכמה מכללא לשימוש שעושה הנתבע בשטח המחלוקת.

91. ודוק. אף אם הייתה נכונה טענת הנתבע כי הסכמות בעלי הדירות ניתנו על דרך של "הסכמה מכללא" לרבות הסכמת הגב' שפירא, הרי שלא שוכנעתי כי התובעת ידעה על הסכמת קודמתה, הגב' שפירא, ולו מכללא, ואם לא ידעה על הסכמה זו- ברי כי איננה מחויבת אליה כחליפה של בעלת הדירה שנתנה הסכמתה, כביכול. לאחר שמיעת עדויות הצדדים, ועל אף שהתובעת רכשה את דירתה לאחר שהנתבע כבר השתלט על שטח המחלוקת, מסתברת בעיני יותר האפשרות שמראש סברה התובעת כי הנתבע הנו פולש שלא כדין אשר עשה דין לעצמו בהשתלטו על הרכוש המשותף.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

92. זאת ועוד. גם אם הייתי מקבלת את טענת הנתבע כי מתקיימת הסכמה מכללא וגם בהנחה שהתובעת ידעה על הסכמה זו, הרי שגם בכך לא די. על מנת שהתובעת לא תוכל לחזור מהסכמת קודמתה על הנתבע להראות, לכל הפחות, כי **הסתמך על הסכמה זו ושינה מצבו לרעה**.

93. במקרה הנדון לא הוכיח הנתבע את הסתמכותו על ההסכמה ושינוי מצבו לרעה בעקבותיה.

94. הנתבע טען בתצהיר עדותו הראשית (ראה שם בסעיף 7) וחזר על כך בסיכומיו (ראה למשל בסעיף 6 לסיכומי הנתבע) כי לשם בניית ההרחבה בדירתו היה צריך לבנות את קירות קומת המרתף, לרבות הקירות בשטח המחלוקת, על מנת שאלו ישמשו כ"יסודות לבנייתה".

95. הנה כי כן, בניית קירות תמך אלו, אשר נועדו במקור לבניית מחסן "לעתיד", היינו עבור דירת התובעת ומאוחר יותר שימשו את הנתבע באופן בלעדי, לא נבנו בהסתמך על הסכמת שפירא כלל. מעבר לכך, הרי שגם לאחר בנייתם הם אמורים היו, לשיטת הנתבע, לשמש את הגב' שפירא (ורק מאוחר יותר, לשיטתו, זו נתנה לו את הסכמתה כי הוא יעשה בהם שימוש).

96. יוצא, כי לכל היותר, הסתמכותו של הנתבע על ה"הסכמות" שנתנה לו שפירא, הן בדמות סגירת אותם קירות ושימוש בהם כמחסן. הנתבע לא הביא כל ראיה בנוגע לעלות סגירת הקירות למחסן בשטח המחלוקת, ואף לא לכל השקעה כספית אחרת שביצע בו. על כן, לא הניח הנתבע כל תשתית ראיתית שיש בה כדי להעיד כי הוציא כספים מרובים בהסתמך על ההסכמות להן הוא טוען.

97. אשר על כן, יש לקבוע כי הנתבע לא הוכיח כי הוציא הוצאות משמעותיות שיש בהן כדי להקים לו טענת הסתמכות. לפיכך, אף אם ניתנה הסכמת שפירא, יכולה התובעת להודיע לנתבע על הפסקת הרישיון שנתנה קודמתה.

98. בהינתן כי שטח המחלוקת הוא רכוש משותף, ובהיעדר הסכמה מצד כל בעלי הזכויות בבית המשותף לשימוש הייחודי שמבצע הנתבע בשטח המחלוקת, אין אלא לקבל את דרישת התובעת, ולהורות לנתבע להפסיק את השימוש הייחודי שהוא מבצע בשטח המחלוקת, ולפנות את שטח המחלוקת מכל חפץ השייך לו.

דמי שימוש

99. מקור סמכותה של המפקחת על המקרקעין לדון ולפסוק דמי שימוש ראויים פורט בהרחבה בפסק דינו של כב' המפקח א. סילברמן בתיק 285/10, **נציגות הבית המשותף רחוב סוקולוב 66 רמת השרון נ' שלמה צפירי** (ניתן ביום 18.1.11, פורסם ב"נבו") ואין לי אלא להצטרף לאסמכתאות המופיעות שם ואל המסקנה לפיה מוסמכת המפקחת לפסוק דמי שימוש ראויים (יוער גם כי הנתבע לא טען להיעדר סמכות).



משרד המכס
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

100. במקרה דנן, משנמצא כי שטח המחלוקת הנו רכוש משותף, אזי ברי כי אין התובעת לבדה זכאית לדמי השימוש וזאת בהסתמך על היתר הבנייה שבידה (שכן, כאמור, אין ההיתר מקנה לתובעת זכויות קנייניות). יוצא כי לכל היותר, זכאית הנתבעת לדמי שימוש עבור חלקה היחסי ברכוש המשותף.

101. על פי עדותו של הנתבע, במשך כשלוש שנים, הוא משכיר את שטח המחלוקת בעלות של 1,500 ₪ לחודש. התובעת לא הציגה נתונים אחרים ולפיכך אני מקבלת בעניין זה את עדות הנתבע. במצב דברים זה, התובע השכיר את שטח המחלוקת לפחות משך 36 חודשים. יוצא כי סך הכל הרוויח הנתבע מהשכרת שטח המחלוקת סך של כ- 54,000 ₪. לכאורה, היה מקום לקחת בחשבון גם את התקופה של שלוש השנים שקדמו להשכרה וגם בהן עשה הנתבע שימוש בלעדי, לטובתו שלו, גם ללא רווח על דרך של השכרה לצד ג'. בשים לב לעלות השכרת המחסן, ניתן לאמוד את הרווח שצמח לנתבע משימוש שהוא עשה במחסן לבדו בסכום דומה, אם כי מעט נמוך יותר, אותו הייתי מעמידה על דרך האומדנה ב-70%, היינו- 47,800 ₪. בשים לב למכלול שיקולים אלו, אומדן שווי השימוש של הנתבע בשטח המחלוקת, בכשש השנים מאז הבנייה בהתאם להיתר הינו 101,800 ₪. דא עקא, כי בכתב תביעתה עתרה התובעת לתשלום דמי שכירות שצמחו לתובע מהשכרת המחסן ולא לתשלום דמי שימוש ("לחייב את הפולש בהחזר דמי השכירות שקיבל ומקבל מאז ועד עצם היום הזה"). לפיכך, אין מקום להתחשב גם ברווח שצמח לנתבע מהשימוש במחסן, טרם השכרתו, ולפיכך יש לחשב את חלקה של הנתבעת מגובה דמי השכירות בלבד.

102. בשים לב לכך שחלקה של התובעת ברכוש המשותף הוא 1/24, הרי שהיא זכאית לקבל דמי שימוש בגין תקופת השכירות בסך של 2,250 ₪.

ד. סוף דבר

103. התביעה לסילוק יד מתקבלת. אני מורה לנתבע להפסיק את השימוש הייחודי שהוא מבצע בשטח המחלוקת ולפנות את שטח המחלוקת מכל חפץ ומיטלטלין השייכים לו וזאת בתוך 45 יום מהיום.

104. התביעה לדמי שכירות מתקבלת חלקית. הנתבע ישלם לתובעת סך של 2,250 ₪.

105. הנתבע יישא בהוצאות התובעת בסך של 4,000 ₪ ובשכר טרחת עורך דינה בסך 6,000 ₪.

106. הסכומים המפורטים לעיל יישאו ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, י' כסלו תשע"ד, 14 נובמבר 2013, בהיעדר הצדדים.

המזכירות תשלח לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

יעל ענתבי- שרון
מפקחת על רישום המקרקעין